

1500076-53.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marco Antônio Costa Neves Buchala

Comarca: Potirendaba

Foro: Foro de Potirendaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... de que o réu estava praticando tráfico e foi apurado que realmente sucedia possibilidades de estar tendo tráfico de drogas naquele local. No dia que cumpriram o pedido de busca, diz que a casa estava com portão e porta da casa abertos, estava apenas o réu na casa, o acusado estava dormindo o qual disse que a droga era para seu consumo próprio. Afirma que não conhecia o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Potirendaba

Foro de Potirendaba

Vara Única

Rua Pedro Siqueira, 1.042, Potirendaba-SP - cep 15105-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500076-53.2022.8.26.0559 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 03/05/2022, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Dr. Marco Antônio Costa Neves Buchala, MM. Juiz de Direito. Eu, Vitoria de Souza Moura, estagiária de nível superior, digitei. Eu, Marcelo Iglesias Teodoro, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500076-53.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - IP nº 2005851 - DEL.POL.NOVA ALIANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ALVES JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marco Antônio Costa Neves Buchala

Vistos.

MARCOS ALVES JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Isto porque, segundo consta da denúncia, no dia 07/01/2022, em torno de 06H00, nas dependências da residência situada na Rua José Camarotto, nº 580, Nova Aliança/SP, o denunciado trazia consigo, tinha em depósito e guardava, com a finalidade de entrega e consumo de terceiros, drogas, consiste em 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, com peso aproximado de 19,43 gramas; além dos petrechos apropriados a traficância, sendo estes, a balança de precisão, embalagens plásticas para acondicionar entorpecente; um recipiente para armazenar a droga e o dinheiro na

quantia de R\$474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01).

O acusado foi atendido pela Defensoria Pública e foi pedido a prisão domiciliar (fls.61/62).

Em audiência de custódia foi indeferido o pedido de prisão domiciliar e convertido de prisão em flagrante para prisão preventiva. Determinando-se a notificação do acusado, com demais providências (fls.69/71).

Determinou-se a notificação do acusado (fls.108), tendo sido apresentada defesa por escrito, através de advogado constituído nos autos (fls.106 e 118/125). Juntou procuração (fls. 107).

A denúncia foi recebida em 01/03/2022 com indeferimento da liberdade provisória e afastamento do exame de dependência toxicológica, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento (fls.141/145 3 152).

O acusado foi citado e intimado pessoalmente (fls.181).

Em audiência instrutória, o acusado foi interrogado, após colheram-se os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, declarando-se encerrada a fase probatória (fls. 205).

Em alegações finais o Ministério Público requer a condenação nos termos da denúncia. Na aplicação das penas pede reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, com exacerbação da pena-base. Pleiteia o regime prisional inicial fechado. Refuta a concessão das penas restritivas de direitos (fls.209/214).

Em alegações finais a ilustre Defesa nega o envolvimento do acusado com a prática do tráfico ilícito de drogas. Pede aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Alternativamente pede seja decretada a internação do acusado em estabelecimento de recuperação de drogados (fls.219/231).

É, na essência, o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Os elementos são seguros e convictos acerca da materialidade delitiva. Vejamos. O auto de prisão em flagrante (fls.01), o boletim de ocorrência (fls.02/04), autos de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação (fls.31/33), fotografias de (fls. 42/48), laudo pericial químico-toxicológico (fls. 94/96), dentre outros indicativos.

A autoria, por sua vez, é convicta.

Na Delegacia, o acusado fez o uso de seu direito de permanecer em silêncio (fls.11).

Interrogado em juízo, o acusado negou a prática criminosa, sob alegação de que a droga se destinava ao consumo próprio. Diz que pediu as substâncias por telefone em São José do Rio Preto e entregaram -lhe na rodoviária de Nova Aliança. Sustenta que separava a droga em porções nos saquinhos de "juju" (sorvete caseiro) para seu uso próprio. Afirmou que a balança de precisão era utilizada por sua esposa para pesar suprimento alimentar e os sacos onde armazenava a droga era também de sua esposa pois ela vende "juju" (sorvete caseiro). Os entorpecentes apreendidos eram armazenados em um pote de creme. Expõe que é usuário de crack, já foi internado em 2017 em Clemente Ferreira por 8 meses, mas não continuou seu tratamento e acabou roubando e voltando ao "uso das drogas". Estava trabalhando como ajudante de serralheiro e soldador. Articula que costuma usar de 6 a 8 balas por dia e afirmou ser usuário de crack e maconha.

Desmerece guarida a versão exculpatória fornecida pelo acusado em seu interrogatório judicial. É pouco acreditável que o agente tenha condições financeiras para reunir volumosa quantidade de cocaína somente para seu consumo. Suas condições financeiras não lhe permitem tal façanha. E, nada, absolutamente nada, faz crer que o acusado estava agindo com mero usuário quando os fatos se deram.

Importante realçar que o acusado já esteve internado para drogadição há mais de 05 (cinco) anos atrás (fls. 127/129). Mas, na atualidade não se viu qualquer sinal de que esteja sofrendo consequências ou malefícios pelo uso de drogas. Sua aparência e

capacidade cognitiva refletiram higidez mental durante a realização da audiência. Em seu interrogatório judicial não surgiram discrepâncias ou sintomas de qualquer prejudicialidade da saúde que pudesse indicar o comprometimento mental pelo consumo de drogas. Aliás, não há nos autos qualquer elemento informativo atual e seguro que indique deficiência da capacidade de discernimento do acusado proveniente do uso constante de drogas. E por conta desses detalhamentos não se viu justa motivação para realização exame de dependência toxicológica, tal como já havia sido decidido, sem qualquer embargo recursal.

Indo adiante, avalia-se a prova oral produzida, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, respeitada a amplitude de defesa.

A Polícia Judiciária Civil já tinha informes seguros sobre o envolvimento do acusado com o comércio de drogas. Arregimentaram indícios dessa prática criminosa para obtenção do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar. E durante o cumprimento de lidima medida judicial surpreenderam o acusado em flagrante delito.

A testemunha de acusação, Paulo Osmar Rizzo Júnior, investigador de polícia, depondo em juízo, declarou que mediante a denúncia feita anonimamente, foi informado que havia tráfico de drogas no local, descobriram a qualificação do réu e foi pedido um mandado de busca, de modo que encontraram as drogas no quarto do acusado, sendo 44 porções, balança de precisão e apetrechos para embrulhar a droga, sendo então saquinhos plásticos. Não recorda encontrar apetrechos para uso. Havia informações de que o réu estava praticando tráfico e foi apurado que realmente sucedia possibilidades de estar tendo tráfico de drogas naquele local. No dia que cumpriram o pedido de busca, diz que a casa estava com portão e porta da casa abertos, estava apenas o réu na casa, o acusado estava dormindo o qual disse que a droga era para seu consumo próprio. Afirma que não conhecia o acusado, pois ele não era erradicado na cidade. Explica que durante as investigações, por algumas vezes que passaram no "ponto de traficância"(local dos fatos), visualizaram a movimentação de usuários de drogas nas proximidades.

A testemunha da acusação Marcos Rogerio Costa, investigador de polícia, ouvido em juízo, declarou que declarou que mediante a denúncia anônima obteve a informação de que havia tráfico de drogas no local onde o réu residia com sua esposa. Foi averiguado com munícipes que haviam pessoas comprando drogas naquele ponto e algumas vezes os viciados usavam drogas ali mesmo. Lograram êxito em identificar o acusado através de diligências conjunta com policiais de Promissão, onde ele já era conhecido por meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas, uso de drogas, furtos e roubos. Esclarece que em cumprimento ao mandado de busca domiciliar judicial a residência estava com portas abertas e ali dentro o acusado dormia. No quarto do acusado foram encontradas varias porções de crack, uma quantidade em dinheiro, uma balança de precisão e varios sacos plásticos, ensejando a sua prisão em situação flagrancial.

A testemunha da acusação Samuel Félix de Moura, agente policial, ouvido em juízo, contou que deu apoio ao cumprimento do mandado de busca domiciliar. Afirma que o portão e a porta da cozinha estavam destrancados, o acusado estava dormindo no quarto, acharam os entorpecentes no local da diligência, sendo então 44 porções de crack, balança de precisão, uma quantia de dinheiro embaixo da cama e saquinhos para armazenar a droga dentro do pote. Informa que as drogas estavam em porções individualizadas nos saquinhos de "juju" (sorvete caseiro), de modo a facilitar a venda. Esclarece que o dinheiro apreendido estava trocado em notas de menor valor econômico. Enfatiza que o acusado dizia ser proprietário da droga destinado ao consumo próprio. Informa que a quantidade encontrada é exagerada para consumo próprio.

A testemunha de defesa Alexandre Rafael Felisbino Gaspere, ouvido em Juízo, afirma que conhece o acusado e sua esposa há dois anos, confirma que sabia que o réu é usuário e era de seu conhecimento que o acusado já havia ficado internado devido ao vício nas drogas. Diz que já havia visto o réu usar drogas em uma praça pública próximo a casa de sua mãe. Argumenta que já viu a esposa do réu vendendo "juju" (sorvete caseiro) na cidade.

A testemunha de defesa Tiago Mendes dos Santos, ouvido em juízo, declarou que conhece o réu há mais ou menos três anos. Explica que moravam próximos e já havia

fornecido a ele trabalho de serralheiro por diária.

A testemunha de defesa Agda Roberta Soares Donega, ouvida em juízo, disse em síntese que conhece o réu há quase dois anos. Tem amizade com a esposa do acusado. Afirma que a esposa trabalha vendendo "juju" (sorvete caseiro) e auferir renda com benefício previdenciário. Alegou que a esposa tinha uma balança pequena prateada para pesar suplemento de academia.

A testemunha de defesa Juliana Regina Favarin dos Santos, ouvido em juízo, declarou que conhece o réu desde que ele saiu da prisão e foi morar na cidade de Nova Aliança. Conhece a esposa do acusado pois faziam academia e também faziam "juju" (sorvete caseiro) para comercializar. Esclarece que a esposa do acusado lhe falou que ele era usuário de entorpecentes. Já viu o réu usando drogas.

As provas amealhadas indicam traços característicos do nefasto comércio de drogas que estava sendo desempenhado pelo acusado, tendo sido surpreendido em flagrante delito na posse de entorpecentes, em condições fáticas indicativas de que a residência familiar servia de "depósito ou esconderijo".

Muito embora as testemunhas de defesa tenham dito que o acusado é usuário ou viciado em consumo de drogas, com certeza, não foi por esse o motivo que o agente criminoso teve a prisão em flagrante decretada. As circunstâncias que nortearam os fatos permitiram aprofundar a investigação policial resultante na apreensão das drogas em depósito próprio de mercadejo.

É surreal a alegação de que o acusado tinha 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína para uso particular. A verdade real que salta aos olhos do julgador é a condição mesclada entre usuário e traficante. Pode ser verdade que o agente seja consumidor de entorpecentes. Mas, nem por isso, afasta-se a tipicidade da conduta criminosa convergente com o delito de maior gravidade, qual seja, a traficância de drogas.

Os atos investigatórios que antecederam a prisão em flagrante já apontavam a casa do acusado como utilizada para servir de ponto de traficância. Ali dentro havia petrechos que servem para separar, embalar e pesar drogas. Também estavam separadas as drogas em pequenas porções acondicionadas de forma compatível com a distribuição varejista.

Usuários não precisam de tais petrechos e não costumam manter um estoque detalhista de entorpecente. Até mesmo porque o usuário ou viciado não consegue guardar drogas, de forma organizada, para o sustento do vício a longo prazo. O consumidor de drogas acaba com tudo. Usa e compartilha toda droga que estiver a seu alcance. Viciados agem dessa forma e com esse ímpeto. Usuários tem comportamento obstinado a consumir entorpecente diuturnamente.

Por tais motivos, os protestos de inocência suflagrados pela defesa técnica não encontram sustentáculo no conjunto probatório. Evidenciou-se a propriedade das drogas imputada ao acusado.

A corroborar os enlaços probatórios temos os depoimentos policiais que exprimem segurança e certeza ao julgador quanto a dinâmica dos acontecimentos, com descrições objetivas, em relação a natureza da diligência policial.

Portanto, o fato é típico, antijurídico e culpável, subsumindo-se a prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei de Drogas.

Pois bem.

A conduta do traficante quando se mescla a condição de usuário de entorpecentes, em nada influência a tipificação delituosa. Inviável, nessa esteira, o acolhimento da pretensão defensiva de desclassificação do tipo penal em questão para o delito de porte ou posse de drogas destinadas ao consumo próprio. Até mesmo porque, o acusado mantinha drogas em modo individual como se fosse destacar, o que é indicativo do tráfico.

Em se tratando de tipicidade subjetiva, embora o "nomem iuris" seja tráfico e este signifique comércio, não se exige expressamente que a conduta se destine à venda ou ao lucro, bastando a consciência e a vontade de realizar um dos elementos do tipo penal.

As condições em que os fatos se deram, sem dúvida, indicam a forma de acondicionamento da cocaína em fração dividida, de forma condizente com a estocagem, sem que estivessem prontas ao uso imediato de entorpecente. Diante dessa

realidade fática-probatória marcou-se os traços característicos de traficância. São figuras equiparadas ao tráfico de drogas a conduta de fornecedor, seja a título gratuito ou oneroso, de entorpecentes para outras pessoas, a fim de consumir drogas. A incriminação também está voltada ao combate à divulgação e disseminação do uso de drogas.

De rigor, à vista disso tudo, a condenação pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas.

Passo, então, a dosimetria.

Atento ao princípio da individualização, observado as diretrizes previstas no art. 59, do Código Penal.

Na primeira fase, oportuno aplicar a Súmula 444, do STJ, a saber: "É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base". Por aqui, define-se antecedentes apenas como condenações criminais com trânsito em julgado não aptas a gerar reincidência.

Esse assunto é Tema nº 129, de Repercussão Geral no STF, sendo apreciado pelo julgamento do RE nº 591054, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26.02.2015.

O acusado ostenta registro de reincidência em certidão própria: condenação anterior por roubo duplamente qualificado – trânsito em julgado anterior ao fato aqui tratado – proc. nº 779-31.2018.8.26.0484 (ação de conhecimento) e proc. nº 4197-56.2019.8.26.0026 (execução penal) – fls. 182/186.

As demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP não lhes são desfavoráveis.

Na primeira fase, fixa-se a pena-base nos patamares mínimos, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, acrescidos do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, aumentam-se as penas em 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, acrescidos do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, vejo que é juridicamente inviável aplicar a causa especial de diminuição, conforme regra do art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas.

São pressupostos legais: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas; d) não integração de organização criminosa.

O STF já pacificou o entendimento de que os pressupostos são cumulativos e não alternativos (RHC nº 110.084 – 1ª Turma – Rel. Min. Luiz Fux).

No caso aqui tratado, o agente é recalcitrante, consoante regramento do art. 63 do CP.

O Colendo STJ tem caminhado para o entendimento de que não configura bis in idem aplicar a agravante genérica da reincidência na segunda fase da fixação da pena e, em seguida, recusar a aplicação do redutor em face da mesma circunstância (HC nº 344737/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – DJe 25/05/2016). O motivo é bem simples, pois o único instituto jurídico pode ser apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, de modo a gerar efeitos diversos.

Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do CP, entendo pela aplicação de 1/30 do salário mínimo, pois não há dados precisos sobre a situação econômica do sentenciado.

A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

A moderação do regime prisional definida pela jurisprudência reinante exige aperfeiçoamento das seguintes súmulas:

Súmula 718 do STF: "A opinião do julgador sobre a gravidade, em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada"

Súmula 719 do STF: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

Pois bem.

Ainda que sejam favoráveis as circunstâncias judiciais há que se considerar a reincidência como fator preocupante e negativista. E não é só. O agente se mudou da cidade maior (local da primeira condenação criminal) para a pequena comunidade interiorana (local da prisão em flagrante), vindo a se empenhar na delinquência

habitual. O detalhe é que Nova Aliança não se tem policiamento ostensivo e a população pacata e ordeira não está acostumada a conviver com a traficância de drogas no acanhado vilarejo. Ali não existe sequer policiamento especializado no combate as drogas (DENARC e etc). As pessoas que sobrevivem em locais dessa pequenez não convivem com disseminação de drogas. É um fator preponderante ao entorno do local dos fatos e deve ser levado em consideração como medida estatal voltada a evitar o aumento desenfreado da criminalidade.

Preocupa-me a migração de criminosos de cidades maiores dotadas de logística privilegiada para locais ermos e pacatos, verdadeiros "povoados" desprotegidos de policiamento ostensivo. Ainda mais nos casos de criminosos que agem com o fito de pulverizar cocaína no meio social, em se tratando de entorpecente destruidor, com alto poder viciante e de impactante nocividade a saúde humana. Dai dizer que o regime inicial mais gravoso é a medida adequada ao caso "sub judice".

Julgado da Suprema Corte voga nas mesmas águas: "1. A pretensão do paciente esbarra na literalidade da norma legal seja na redação original, seja na redação atual -, já que as penas privativas de liberdade aplicadas para os agentes que cometem crimes hediondos ou equiparados terão obrigatoriamente que ser cumpridas em regime inicialmente fechado. 2. Não há que se falar em violação aos princípios de dignidade da pessoa humana, individualização da pena e proporcionalidade, como pretende o impetrante" (STF, HC 103011/RN, 2ª T., Relatora Ministra ELLEN GRACIE, LexSTF 382/450).

Outros pronunciamentos das Cortes Superiores não deixam dúvida sobre a sensatez do raciocínio (STJ, AgInt no TEsp 1590865/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado 16-08-2016; HC 362598/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DAFONSECA, julgado 15-09-2016; HC 367048/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 18-10-2016; AgRg no HC 325536/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 06-10-2016; HC 360552/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 22-11-2016; HC 373853/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 22-11-2016), especialmente do Excelso Pretório (STF, HC 130375 AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado 13-09-2016; HC 136361/DF, julgado 26-10-2016; RHC 122870/AL, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado 25-10-2016; HC 138186 AgR/MS, Relator Ministro EDSON FACHIN, julgado 06-12-2016).

Adoto, por tais motivos, o REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MARCOS ALVES JÚNIOR, já qualificado, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, acrescidos do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no teto unitário mínimo, em regime prisional inicial FECHADO, por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O sentenciado respondeu aos atos e termos da presente ação penal enclausurados, motivo pelo qual devem recorrer na mesma condição processual. Persistem os motivos da prisão cautelar. Fortalecidos os indícios da autoria e da materialidade, após detida análise probatória, concluiu-se pela condenação. Por se tratar de prática criminosa em que o acusado Marcos é experiente no mundo da marginalidade (reincidência) vindo demonstrar "profissionalismo criminoso" em seu modo de agir mantendo estoque considerável de "cocaína", de forma afrontosa a ordem pública, além de que poderá se furtar da aplicação da lei penal caso seja libertado antes de cumprir a reprimenda que lhe foi imposta. Ademais, a quantidade expressiva de drogas também é um fator marcante para indicar periculosidade ao meio social e a paz pública, devendo prevalecer a supremacia do interesse de ordem pública.

Expeça-se carta de guia provisória ou definitiva, conforme o caso. Após, o trânsito em julgado, em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunique-se a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Declaro a perda de valores e objetos apreendidos em prol da União.

Desnecessário recomendar o sentenciado na prisão, em razão da revogação expressa do art. 393 do CPP, após promulgação da Lei nº 12.403/2011.

Com o trânsito em julgado, se for o caso, expeça-se mandado de prisão em regime prisional inicial FECHADO.

Custas são devidas, conforme dispõem os arts. 804 e 805 do CPP, contudo o advogado constituído requereu o benefício da justiça gratuita, sendo compatível seu pedido com a situação financeira do sentenciado verificada pelas próprias circunstâncias fáticas, permitindo-lhes ser agraciado pela assistência judiciária. Fica, então, suspenso o ônus (art. 98, parágrafo 3º, do CPC).

Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Potirendaba, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA